

1503263-10.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valinhos

Foro de Valinhos

1ª Vara

Rua Professor Ataliba Nogueira, 36, Valinhos-SP - cep 13270-660

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503263-10.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503263-10.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2342293/2019 - 01º D.P. VALINHOS, 8731330 - 01º D.P. VALINHOS, 1162/19/354 - 01º

D.P. VALINHOS, 2342293 - 01º D.P. VALINHOS, 1162/19/354 - 01º D.P. VALINHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

SANDERSON CRISTIAN THEODORO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de SANDERSON CRISTIAN THEODORO, já qualificado nos autos, na qual lhe imputa a prática da infração penal descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Narra-se na denúncia que no dia 26 de novembro de 2019, por volta das 11h, no interior da residência localizada na Rua Vitória Baron, n. 8, Fundos, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Valinhos, o acusado tinha em depósito 130g de Cannabis Sativa L, dividida em 92 porções distintas, 12,2g de cocaína, na forma de 27 pedras de crack, e 54,4g de cocaína, dividida em 121 porções, para fins de comercialização e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Consta na denúncia, ainda, que “na data supra, em razão de informações anônimas dando conta que no imóvel situado na Rua Vitório Baron, n. 08, casa dos fundos, Zona Rural, nesta cidade, um indivíduo estaria comercializando entorpecentes, os guardas municipais Jesuíno Honório Pereira e Marcio Roberto Banhe rumaram para lá. Lá chegando, foram recebidos pelo proprietário do imóvel, Sr. João Gerson Manoel Mason, residente na casa da frente, o qual, após ser indagado a respeito da denúncia anônima de tráfico de drogas que recaía sobre seu inquilino, franqueou a entrada dos agentes, que ao caminharem pelo corredor do imóvel divisaram o denunciado e decidiram abordá-lo. O denunciado, durante a abordagem, e em resposta às indagações dos guardas municipais quanto à existência de entorpecentes no local, confirmou que guardava no local certa quantidade de drogas para seu consumo próprio, razão pela qual os agentes decidiram ingressar no interior da residência de SANDERSON e realizar buscas pelo local. Em busca pela moradia, os guardas municipais lograram localizar 92 porções de maconha, sendo que 02 delas, maiores, no interior da geladeira e 90 divididas dentro de uma pochete sobre um colchão na sala e de uma gaveta da escrivaninha do quarto, 27 pedras de crack e 121 porções de cocaína, guardadas em quantidades diversas dentro da pochete que estava sobre o colchão da sala e dentro da gaveta da escrivaninha do quarto, além de um aparelho de telefonia celular, a quantidade de R\$845,85 em dinheiro, e apetrechos utilizados no preparo de entorpecente, como balança e facas.”

Notificado (fls. 154), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 159/162). Recebida a denúncia (fls. 173/175), foi citado (fls. 194).

Audiência de instrução e julgamento ocorrida em 08 de junho de 2022, momento em que ouvidas 02 testemunhas comuns à defesa e à acusação e, por fim, interrogado o réu.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia, observando-se a fixação do regime inicial fechado. A defesa requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas, em razão de operação conduzida pela guarda municipal, conseqüentemente, dos elementos de prova dela advindos e a conseqüente absolvição do acusado. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

A questão preliminar relacionada à ilicitude das provas colhidas se confunde com o mérito da pretensão punitiva, pois tangencia a materialidade delitiva, razão pela qual será analisada oportunamente. Não se implementou prazo prescricional, tampouco nenhuma outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

Para o exame da comprovação da materialidade do fato descrito na denúncia, são relevantes, em especial, os seguintes elementos de informação e de prova: auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), laudos de exame pericial preliminar (fls. 50/52) e definitivo (fls. 121/123).

Ocorre que para a aferição da licitude e validade da prova da materialidade, imprescindível que sejam analisadas as circunstâncias em que se deram sua coleta. No ponto, passa-se a sumarizar os depoimentos colhidos.

A testemunha Jesuíno Honorio Pereira, guarda municipal, ouvido em solo policial, aduziu que (a) receberam denúncia anônima da ocorrência de tráfico de droga na rua Vitório Baron, n. 08, Jardim das Figueiras, (b) o denunciante, que não quis se

identificar, apontou aos guardas que acreditava ser aquele local ponto de comercialização de drogas, (c) chegando ao local, o proprietário do imóvel autorizou a entrada dos guardas e, ao ingressarem, se depararam com o denunciado no corredor da casa, sendo abordado, (d) confessou de pronto a prática do crime, mostrando aos guardas onde se encontrava a droga e o dinheiro. Em Juízo, a testemunha ratificou o alegado anteriormente, acrescentando que (e) o Município dispõe de telefone para denúncias desta natureza, (f) após receberam a denúncia, se deslocaram até o local dos fatos, havendo grande movimentação de pessoas, (g) encontraram o proprietário do imóvel, franqueando prontamente a entrada dos guardas na casa, (h) ao abordarem Sanderson no corredor, ele confessou imediatamente a traficância, (i) o imóvel é composto por uma construção na frente e outras aos fundos, onde o acusado mantinha um quarto, (j) a entrada de ambas as construções se dá pela frente, (k) não tinha conhecimento de que havia outro quarto alugado no mesmo imóvel, (l) ao abordarem Sanderson no corredor do imóvel, nada de ilícito foi encontrado com ele, (m) o acusado é conhecido nos meios policiais pela prática do mesmo delito.

A testemunha Márcio Roberto Banhe, guarda municipal, ouvido em solo policial, aduziu que (a) receberam denúncia anônima da prática de tráfico de drogas na Rua Vitória Baron, n. 08, Jardim das Figueiras, (b) chegando ao local, o proprietário do residência que mora na casa em frente, no mesmo quintal do acusado, franqueou a entrada dos agentes, (c) no corredor da residência um indivíduo foi abordado e prontamente confessou que havia droga e dinheiro em sua casa, indicando aos guardas onde estavam acondicionados, (d) confessou que a droga era destinada à comercialização, e o dinheiro produto do tráfico. Em Juízo, a testemunha ratificou os fatos narrados anteriormente, acrescentando que (e) a guarda municipal vem atuando ostensivamente, realizando flagrantes desta natureza.

Por fim, o acusado Sanderson Cristian Theodoro, em solo policial, alegou que (a) se encontrava dormindo, quando se levantou para ir até a cozinha e verificou que a porta estava aberta, (b) observou que guardas municipais estavam na porta de sua casa, e lhe chamaram para sair do imóvel, com uma arma de fogo apontada em sua direção, (c) é viciado em maconha, cocaína e crack há 13 anos, e acabou dizendo aos guardas que havia droga de sua propriedade, para consumo próprio, dentro de sua casa, indicando onde se encontrava, (d) o dinheiro encontrada era destinado ao pagamento da pensão de seu filho, (e) ao ser algemado e conduzido ao quarto, o GM Marcio Banhe passou a lhe "das umas bicudas", desferindo pontapés, socos e o jogou no chão, tudo isso algemado, (f) chegou a indagar os guardas se havia algum mandado para ingresso no imóvel, momento em que o GM Marcio lhe respondeu que "quem fazia o mandado era ele", (g) o outro guarda que conduzia a ocorrência não falou nada e também não fez nada para impedir a conduta de Marcio. Ouvido em Juízo, o acusado alegou que (h) o Sr. João, pessoa de quem ele alugava um quarto aos fundos da residência, não se encontrava em casa, mas em um bar a cerca de 200m do local, (i) o Sr. João foi abordado no interior do bar e conduzido até o imóvel, (j) tinha acabado de acordar e, quando abriu a porta, já se deparou com os guardas municipais, (k) alegaram os guardas que havia denúncia anônima de tráfico naquele local, momento em que o acusado disse ser usuário, possuindo certa quantia de droga para uso próprio, (l) a casa tinha dois quartos aos fundos, alugados para ele e mais um outro rapaz, (m) a elevada quantidade de droga que mantinha é justificada pelo fato de já ter passagens policiais e não queria frequentar locais de venda de droga.

Diante do acervo probatório acima sumarizado, a despeito das substanciosas razões apresentadas pelo Ministério Público em alegações finais pela condenação, constata-se que a absolvição por ausência de prova (CPP, art. 386, VII) se impõe, pois é consectário da ilicitude da empreitada investigativa e ostensiva empreendida pela guarda municipal, que levou à entrada em domicílio (meio de obtenção de prova), a qual implica a ilicitude da subsequente apreensão das drogas e respectiva perícia, por ser prova derivada, à luz do art. 5º, LVI, da CR/1988 e do art. 157, caput e §

1º, do CPP. Explico.

As guardas municipais exercem relevante serviço público de segurança, em sentido lato, nos termos do art. 144, parágrafo 8º, Constituição da República. Ocorre que suas funções se restringem à proteção do patrimônio municipal, incluídos os seus bens, serviços e instalações.

Em observância à função constitucional atribuída às guardas municipais, é certo que lhes é permitida a realização de patrulhamento preventivo, mas sempre vinculado – o patrulhamento –, à finalidade de tutelar o patrimônio público municipal.

Consequência lógica do raciocínio acima esposado, não incumbe à guarda municipal empreender operações de combate ao tráfico, realizar patrulhamento ostensivo em locais conhecidos pela comercialização de substâncias entorpecentes.

Ainda nesta linha, mostra-se teratológica a situação ora apresentada: guardas municipais, ao receberem denúncia anônima de tráfico de drogas – em telefone disponibilizado pelo ente municipal especificamente para denúncias –, se deslocaram até o local, em verdadeira operação de natureza policial – em sentido estrito –, para averiguação dos fatos. Para tanto, abordaram o indivíduo que se dizia proprietário do imóvel e alugava um dos quartos ao acusado. Ato contínuo, adentraram no imóvel para a abordagem do acusado e sua revista pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito.

Mas, supostamente, nos termos da narrativa dos guardar municipais em juízo, o acusado de pronto assumiu a traficância e indicou o local em que acondicionadas as drogas. Tal versão, cada vez mais recorrente, não se mostra minimamente plausível. Relevante salientar que o acusado teve sua prisão em flagrante relaxada quando da realização de custódia (fls. 63/64).

Registre-se, no ponto, que não há outras provas obtidas por fonte independente que possam, com base em nexo de causalidade diverso, dar amparo à comprovação do fato-crime, à luz do art. 157, § 1º, do CPP, e tampouco há no caso demonstração de hipótese de descoberta inevitável pelos trâmites típicos e de praxe da investigação, à luz do art. 157, § 2º, do CPP.

O laudo pericial sobre as drogas apreendidas é o único meio de prova admitido na legislação processual penal para a comprovação do tráfico de drogas (CPP, art. 158), conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AgRg no HC 492.906/MS, Quinta Turma, DJe 12/09/2019 e HC 497.242/CE, Sexta Turma, DJe 12/08/2019).

Diante da dinâmica fática supra sintetizada, bem evidenciada pela instrução processual, não há como afastar a ilicitude do meio de obtenção de prova empregado, pois a guarda municipal, ao realizar operação de natureza policial para averiguação do crime de tráfico de drogas, em imóvel privado – e não público, pertencente ao ente municipal –, agiu em flagrante desvio de finalidade às suas funções constitucionais. Trata-se de entendimento adotado pelo C. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador

constituente - apesar das investidas em contrário - por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil - em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência - estão sujeitas a rígido controle correccional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais - apesar da sua relevância - não estão sujeitas a nenhum controle correccional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar - em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais - o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para "Polícia Municipal". Ademais, inúmeros municípios pelo país afora - alguns até mesmo de porte bastante diminuto - estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

6. Ao dispor no art. 301 do CPP que "qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de "qualquer do povo"; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham

sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12. Recurso especial provido."

(REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Tendo em vista que toda a prova da materialidade do delito foi obtida a partir de atividade com desvio das finalidades atribuídas aos agentes públicos municipais, deve ser reconhecida a sua ilicitude por derivação.

Não se nega que o tráfico de drogas é crime grave, que traz consigo consequências sociais diversas e indesejáveis. Ocorre que o Estado-Juiz, ao se deparar com afrontas à ordem constitucional praticadas pelo próprio Estado, sob alegação de combate ao crime, não deve ratificar tais condutas.

No ponto, é elucidativa a célebre e já quase centenária passagem do Justice Louis D. Brandeis, da Suprema Corte americana: "Em um governo de leis, a existência do Estado estará sob risco se este deixar de observar a lei escrupulosamente. O Estado [...], bem ou mal, orienta todo o povo pelo seu exemplo. O crime é contagioso. Se o Estado se torna um infrator da lei, ele convida à anarquia. Declarar que, na administração da justiça criminal, os fins justificam os meios - declarar que o Estado pode cometer crimes com o objetivo de assegurar a punição de um determinado criminoso - atrairia um terrível castigo" (Olmstead v. United States 277 US 485, 1928, tradução livre).

Portanto, embora as provas apontem sim a materialidade e a autoria da infração penal (notadamente confissão informal e apreensão da droga, conforme indicado pelo Ministério Público), tais provas são ilícitas por derivação e, conseqüentemente, inadmissíveis na forma do art. 5º, LVI, da CR/88 e do art. 157, caput e § 1º do CPP. Logo, impõe-se a absolvição por ausência de provas lícitas aptas à comprovação da materialidade e autoria da infração penal descrita na denúncia.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de ABSOLVER SANDERSON CRISTIAN THEODORO da imputação contra si formulada neste feito, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Promova-se a destruição das amostras de droga eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Promova-se a restituição dos valores apreendidos ao acusado, na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Sem custas (CPP, art. 804).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º).

Intimem-se o Ministério Público, a defesa técnica e o acusado.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Valinhos, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA